

1500243-15.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500243-15.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2056179/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 23284432 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2056179 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS FELIPE ALVES GOMES DE MORAES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

MATHEUS FELIPE ALVES GOMES DE MORAES e PAULO HENRIQUE CARDOSO PEREIRA DA SILVA foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", e do artigo 35, c.c. artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei 11.343/2006, porque no dia 25 de

fevereiro de 2022, na Avenida São Lourenço, nº 86, São Lourenço, nesta cidade e Comarca, nas imediações de um estabelecimento de ensino, agindo em concurso com unidades de desígnios entre si e envolvendo o adolescente Rodrigo Antonio da Silva Pinto, traziam, para consumo de terceiros, quarenta e sete pedras de crack, vinte e oito papелotes de cocaína, dois tijolos de maconha, pesando 325 gramas, sessenta e nove pedras de crack, quarenta e sete pedras de crack e vinte e oito micro-tubos de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, associaram-se com o adolescente Rodrigo Antonio da Silva Pinto para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Devidamente notificados, os acusados apresentaram defesa preliminar a fls. 191/192. Recebida a denúncia aos 05 de maio de 2022 (fl. 194), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se três testemunhas de acusação e, ao final, promoveram-se os interrogatórios dos acusados (fl. 241).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência parcial da ação, certa de que as provas estão em sintonia e autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pugnando pela absolvição quanto à associação, manifestando-se, ainda, quanto à ausência de comprovação quanto ao envolvimento do adolescente na prática criminosa (fls. 257/269).

A defesa pugnou pela absolvição do crime de associação embasada na ausência de provas das autorias, além de combater as causas de aumento de pena denunciadas. Quanto ao tráfico, postulou o reconhecimento da atenuante da confissão e de causa de diminuição (privilegio), além da imposição de regime mais brando (fls. 277/308).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está plenamente comprovada. Os laudos de exame químico toxicológico (fls. 146/154) descreveram e concluíram que as substâncias analisadas são cocaína e maconha, caracterizadas por meio de análises químicas e cromatográficas.

Pelos testemunhos colhidos as autorias também se evidenciaram.

Matheus e Paulo admitiram a prática da infração e se mostraram arrependidos.

Argumentaram, contudo, que não se conheciam, tampouco o adolescente Rodrigo, apreendido durante a diligência, além de salientarem que, embora tenham sido capturados no mesmo lugar, não atuavam em conjunto no tráfico de drogas.

Suas confissões estão em harmonia com as demais provas. Senão vejamos.

O PM Juliano relatou que naquele dia durante patrulhamento de rotina na rua São Marcos, conhecido ponto de tráfico de drogas, avistou três indivíduos.

Declarou que assim que notaram a presença da viatura da polícia militar, todos tentaram empreender fuga, razão pela qual foram perseguidos e capturados. Realizada revista pessoal, em poder de Paulo apreendeu duas porções grandes de maconha e sessenta e nove pedras de crack. Indagado sobre as drogas, ele admitiu que estava realizando o tráfico de drogas.

Acrescentou, ainda, que seus colegas de farda também localizaram drogas em poder do coacusado Matheus e com o adolescente Rodrigo, razão pela qual todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Por sua vez, o PM Thiago Adinolfi ratificou a versão apresentada por seu colega.

Ele contou que naquela oportunidade, tão logo observou os acusados fugindo, foi em perseguição a um deles, o coacusado Matheus, o capturou mais adiante. Mencionou que apreendeu em seu poder uma pochete contendo 47 pedras de crack e 28 papелotes de cocaína, além de uma quantia em dinheiro (R\$ 147,00). Declarou, também, que Matheus admitiu que a droga apreendida em seu poder estava destinada ao comércio ilícito de drogas.

Por fim, o PM Thiago Ítalo, que também participou da diligência que culminou com a

prisão dos acusados, narrou a fuga dos agentes e do adolescente assim que avistaram a viatura policial, bem como informou que a ele coube perseguir e apreender Rodrigo (adolescente), além de certificar o encontro de drogas em seu poder.

Nada existe nos autos a demonstrar que os policiais responsáveis pela prisão dos acusados tivessem qualquer motivo para imputar a eles, indevidamente, a prática de crime, em especial da gravidade do denunciado. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a situação de traficância.

Por isso mesmo, a intenção de comerciar fica consubstanciada visto que tais provas apontam claramente para esta finalidade dos agentes. Não há nada que possa desabonar o depoimento dos policiais envolvidos, pois seus atos presumem-se legítimos por força de princípio administrativo.

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito".

Destarte, o argumento de que seus depoimentos estariam comprometidos pelo fato de terem o dever legal de justificar sua atividade não pode ser aceito. Se o fosse, estaria estabelecido preconceito odioso em relação a pessoas que auxiliam a justiça na busca da verdade real.

Assim, seus depoimentos são analisados e cotejados com os demais elementos carreados aos autos, sem maior ou menor relevância pelo fato de serem agentes de segurança do Estado, responsáveis pela repressão ao crime.

Neste diapasão, tem se manifestado a jurisprudência ao tratar do depoimento policial. Veja-se:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

Repise-se, assim, que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são harmônicos e uníssonos. Frise-se também que os agentes públicos em seus depoimentos esclareceram, sem nenhuma contradição entre eles, o ocorrido naquela ocasião, inclusive com riquezas de detalhes demonstrando toda a operação realizada desde a chegada ao local, a fuga dos agentes e suas capturas, assim como a apreensão das drogas, não havendo, em princípio, nada que desabone esses depoimentos.

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROCESSO PENAL - PROVA -DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - IDONEIDADE -RECONHECIMENTO. É idônea a prova testemunhai colhida, constituída do depoimento dos policiais que efetuaram a diligência. (TJ-SP - APL: 993061147033 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 04/05/2010, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2010)

APELAÇÃO. INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito. Tendo em vista que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito têm natureza de "crimes permanentes", admite-se a prisão em flagrante sempre, ainda que esta prisão seja realizada no interior de uma

residência. Precedentes do STF. 2. As autorias e as materialidades dos crimes de tráfico de drogas e roubos, um majorado e outro simples, restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas na casa do réu e os objetos roubados encontrados em sua posse. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 12. O instituto da detração, para ser aplicado, depende da análise da situação processual do sentenciado, inclusive no que concerne a eventuais condenações e unificação de penas. Portanto, o Juízo das Execuções Penais é a sede mais adequada para a apreciação da matéria. 13. Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00628017920128260050 SP 0062801-79.2012.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância entorpecente foi encontrada na posse de um dos réus, como também porque restou comprovado o vínculo associativo entre ambos os dois para fins da prática, reiterada ou não, do comércio espúrio, mercê de provas idôneas e suficientes para as suas responsabilizações. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. 3. Dosimetria da pena fixada de modo escorreito. 4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. Ademais, "in casu", o regime fixado continua sendo o fechado, mercê da pena imposta aos réus, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 5. Improvimento dos recursos das defesas. (TJ-SP - APL: 00015180220118260370 SP 0001518-02.2011.8.26.0370, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/04/2014) Não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as provas orais colhidas.

A finalidade de traficar está bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, a variedade de espécies, o local e as circunstâncias como foram os agentes encontrados, a par de suas confissões, tudo indica para uma guarda com a intenção de tráfico, venda.

O crime de tráfico ilícito de drogas traz em seu tipo penal vários verbos que exprimem as formas de conduta puníveis, algumas de natureza instantânea, outras permanentes, não sendo necessário para sua configuração tenham os agentes efetuado a venda. Basta que a possuam ou tenham em depósito com o fim de colocá-la em circulação, incorrendo, assim, em uma das figuras do tipo.

Em escólio à norma em apreço, o renomado VICENTE GRECO FILHO leciona a respeito da prescindibilidade da ocorrência da venda do produto, assim asseverando:

"Para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos" (Tóxicos - Prevenção - Repressão. Saraiva, 1987, p. 81.)

A esse respeito, esclarecedor é o seguinte julgado:

"Para a consumação do delito de comércio clandestino de entorpecente, não importa que o produto não tenha sido distribuído à venda. Consuma-se ele embora não tenha resultado o dano. Seu não-exaurimento, porém, é irrelevante, vez que não, ficou afastada a real periclituação do bem jurídico penalmente protegido. Nem se há de falar na hipótese de crime impossível." (RT 401/75)

Nas modalidades que configuram crime permanente, ou seja, expor a venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, etc... evidenciado o início da execução, tem-se o crime por consumado.

Ora, as condutas praticadas pelos acusados amoldam-se perfeitamente às figuras "trazer consigo e guardar", previstas no tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

No mais, a apreensão de apreciável quantidade de substância entorpecente, conduz à segura conclusão de estar configurado o delito de tráfico.

Não obstante os argumentos já expendidos em relação ao crime de tráfico, não deve prosperar a imputação de associação para tal finalidade.

Isto porque os acusados nada admitiram neste particular. Nenhum vestígio existe a respeito de uma eventual associação duradoura e estável entre eles e o adolescente infrator. Os policiais nada relataram sobre a associação imputada.

O crime de associação se distingue do concurso eventual de pessoas que exige um acordo de vontades ocasional e efêmero para a perpetração de determinado crime; a associação pressupõe ajuste permanente ou estável para a perpetração de vários crimes de tráfico de entorpecentes (mínimo dois).

A propósito, dispõe o artigo 35: Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1.º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Com efeito, são pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a reiteração ou não "julgado e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33 e 34 da lei nº 11.343/2006, com dolo específico ou elemento subjetivo do tipo, não havendo necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer.

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos de sua definição.

Neste sentido preleciona Vicente Greco Filho:

"Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração..."(GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: Prevenção - Repressão: Comentários à Lei n.º 10.409/2002 e à parte em vigor da Lei 6368/76 - 12.ª ed. Atual. - São Paulo - Editora Saraiva - 2006 - p. 127).

Portanto, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris* em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico.

Na espécie, repise-se, inexistem elementos sólidos a embasar o édito condenatório, não havendo como reconhecer, in casu, o delito de associação.

Restando, pois, incomprovado o animus associativo mais ou menos estável ou permanente, não há que se falar em associação para o tráfico, pois, para a sua caracterização é indispensável à associação de duas ou mais pessoas; acordo dos parceiros; vínculo associativo; e a finalidade de traficar tóxicos, formando uma verdadeira *societas sceleris* para essa finalidade.

Não se vislumbrou a ocorrência de outros crimes de tráfico, como ainda, uma estabilidade na relação entre os acusados e o adolescente, razão pela qual suas absolvições se impõem, tanto é que a própria acusação pugnou nesse sentido. Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelos condenados não justifica aumento nas penas-base.

Matheus não possui maus antecedentes. Contudo, os antecedentes de Paulo recomendam exacerbação, conforme indicam as certidões de fls. 64/66. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade dos agentes. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, estes fatos de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Não há participação de vítima no tráfico a ser considerada na dosimetria da pena. Ausentes as circunstâncias judiciais acima expostas, que devem levar à exacerbação das penas-base, fixo as penas de Matheus em seus patamares mínimos. Quanto a Paulo, presente a circunstância judicial elencada, suas penas serão fixadas em 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa no patamar mínimo legal.

Na segunda etapa, certificada a reincidência de Paulo (fl. 63), não utilizada para efeitos de maus antecedentes, observo que ela concorre com a atenuante da confissão, razão pela qual serão compensadas, não havendo outras atenuantes ou agravantes a considerar, principalmente quanto ao coacusado Matheus.

Na etapa final, deve ser reconhecida a causa especial de aumento denunciada, prevista no artigo 40, inciso III, uma vez que a prova é segura no sentido de que a infração foi praticada nas imediações de um estabelecimento de ensino.

O lugar do crime está a 100 metros de uma escola, conforme certificou o laudo anexo (fls. 138/140). Logo, há proximidade entre os locais, verificando-se a influência e o potencial perigo que o comércio ilícito pode acarretar.

Ressalte-se que para o reconhecimento da majorante não é necessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei, tampouco que a substância entorpecente de fato atinja, diretamente, os estudantes, as pessoas hospitalizadas etc., sendo suficiente que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades.

Pretende a lei proteger tais locais, frequentados por grande quantidade de pessoas, algumas delas, em condições especiais. Portanto, o perigo à saúde pública é maior nestes locais, não exigindo a lei que o estabelecimento seja especialmente visado pelos agentes.

Nesse sentido:

"Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da lei nº 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância.(HC n. 407.487/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 15/12/2017).

"A prática do delito de tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimentos de ensino enseja a aplicação da majorante, sendo desnecessária a prova de que o ilícito visava atingir os frequentadores desse local (STJ. 6ª Turma. AgRg no Resp. 1558551/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/09/2017 STJ; 6ª Turma. HC 359088/SP. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 04/10/2016).

Diante da proximidade entre os locais, está latente que havia conhecimento da situação pelos acusados, razão pela qual as penas serão aqui elevadas em razão desse fator (Matheus – 5 anos + 1/6 = 5 anos e 10 meses/500 dias + 1/6 = 583 dias-multa/Paulo – 6 anos + 1/6 = 7 anos /600 dias + 1/6 = 700 dias).

Prosseguindo, não deve prosperar a causa de aumento prevista no inciso VI, uma vez que a prova dos autos não demonstrou com segurança que o adolescente colaborava com os acusados na venda das drogas, em que pese tenha havido apreensão de drogas em poder de todos os envolvidos. Tudo indica que comerciavam drogas de forma distinta, cada um por si.

Ainda que pudessem estar agindo a mando de um traficante maior, não existe prova

segura de uma atividade conjunta, associada entre eles. Anote-se que o depoimento dos policiais apenas asseveraram que os acusados e o adolescente estavam no mesmo local, contudo, não descreveram se eles estariam agindo em conjunto na ocasião. Paulo é reincidente, razão pela qual não faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Por sua vez, Matheus é primário, portador de bons antecedentes criminais e, nestes autos, não se demonstrou que ele tenha envolvimento ou integre organização criminosa. Logo, amolda-se na hipótese de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Assim sendo, suas penas serão diminuídas em 2/3 (5 anos e 10 meses - $2/3 = 1$ ano, 11 meses e 10 dias - 583 dias - $2/3 = 194$ dias).

Para início do cumprimento da pena fixo o regime aberto para Matheus, levando em consideração as circunstâncias judiciais favoráveis, a sua primariedade, o reconhecimento do tráfico privilegiado e do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 596.603:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. 1. Ante a necessidade de salvaguardar um dos direitos fundamentais mais preciosos do ser humano, a liberdade, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 143.641/SP, rompeu com a resistência registrada nos seus precedentes, quanto à inadmissibilidade do uso do writ constitucional de maneira coletiva. Na oportunidade, assentaram-se diretrizes a respaldar o maior espectro do remédio heroico, entre elas: a existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis; o fortalecimento da abordagem coletiva, em atendimento a maior isonomia às partes em litígio e em prestígio à celeridade processual, mitiga as dificuldades estruturais do acesso das coletividades ao Poder Judiciário. 2. A moldura fática trazida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo – mais de mil presos, que, a despeito da reconhecida prática de crime de tráfico privilegiado, cumprem pena de um ano e oito meses, em regime fechado, com respaldo exclusivo no ultrapassado entendimento de que a conduta caracteriza crime assemelhado a hediondo – permite solução coletiva, por reproduzirem a mesma situação fático-jurídica. Precedente (HC n. 575.495/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, julgado em 2/6/2020, DJe 8/6/2020). 3. Há anos são perceptíveis, em um segmento da jurisdição criminal, os reflexos de uma postura judicial que, sob o afirmado escudo da garantia da independência e da liberdade de julgar, reproduz política estatal que se poderia, não sem exagero, qualificar como desumana, desigual, seletiva e preconceituosa. Tal orientação, que se forjou ao longo das últimas décadas, parte da premissa equivocada de que não há outro caminho, para o autor de qualquer das modalidades do crime de tráfico – nomeadamente daquele considerado pelo legislador como de menor gravidade –, que não o seu encarceramento. 4. Segundo a interpretação, consolidada e antiga do Supremo Tribunal Federal (HC n. 111.840, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 17/12/2013), conforme à Constituição da República, não é considerado hediondo o delito de tráfico de drogas, na modalidade prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006 (caracterizada pela quantidade de drogas apreendida não elevada e por ser o agente primário, sem antecedentes penais e sem envolvimento com atividade ou organização criminosa). 5. Em decorrência dessa interpretação, que sobreleva os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, a natureza não hedionda do

crime em exame desautoriza prisão preventiva sem a análise concreta dos requisitos do art. 312 do CPP (HC n. 104.339, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 06/12/2012), afasta a proibição, prevista art. 44 da Lei 11.343/2006, de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos (HC n. 97.256, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ayres Britto, DJe 15/12/2010), e impõe, portanto, tratamento penal com "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa" (HC n. 118.533, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 19/9/2016). 6. Quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena, é clara e reiterada a dicção de enunciados sumulares dos Tribunais Superiores, segundo os quais "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" (Sum. 718 do STF), "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Sum. 719 do STF) e "É vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade do delito" (Sum. 440 do STJ). 7. Esses julgados, por força do art. 927, III e V, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão da norma de abertura positivada no art. 3º do CPP, devem ser observados por juízes e tribunais do país, em nome da segurança jurídica, da estabilidade das decisões do Poder Judiciário, da coerência sistêmica e da igualdade de tratamento dos jurisdicionados, que não podem ficar à mercê de interpretações divergentes, sobre questões de cunho eminentemente jurídico, das que lhes conferiram os órgãos de cúpula do Poder Judiciário, incumbidos, por comando Constitucional, da função de uniformizar a interpretação e a aplicação da Constituição da República e das leis federais (arts. 102, III e 105, III). 8. A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que conferiu nova redação ao art. 112, § 5º, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006". 9. Deveras, não condiz com a racionalidade punitiva, ínsita a um Estado Democrático de Direito, que a todo e qualquer autor de tráfico de drogas se imponha o cumprimento de sua pena em estabelecimento penal, em regime fechado, e sem direito a qualquer alternativa punitiva, mesmo se todas as circunstâncias judiciais e legais sejam reconhecidas a seu favor (quantidade pequena de droga, primariedade e bons antecedentes do agente, além de não demonstração de seu envolvimento em atividade ou organização criminosa). 10. E não há de ser esse o proceder de agentes do Estado a quem se confia o exercício da nobre função de dizer o Direito, algo que, no âmbito da jurisdição criminal – que expressa o poder punitivo estatal – reclama dose ainda maior de serenidade e ausência de preconceitos. 11. A individualização da sanção penal (alçada a direito fundamental, inscrito no art. 5º, XLVI da Constituição da República) não se limita à quantidade da pena; o seu regime e a modalidade da reprimenda imposta também compõem essa ideia, que carrega em si a proporcionalidade da pena. Se o Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente (art. 33, § 2º c/c 59, do CPB), permitindo também substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPB), não há razão para impor-se a condenados pela modalidade mais tênue do crime de tráfico de entorpecentes o mesmo regime de pena que, ex vi lege, se costuma impingir somente a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por tráfico, a mais de 8 anos de pena, ou a reincidentes ou portadores de circunstâncias desfavoráveis. 12. A documentação, trazida em aditamento à impetração, alude a 1100 homens e mulheres que cumprem pena em regime fechado no sistema penitenciário do Estado de São Paulo, e sem lhes haver sido autorizada a conversão da privativa de liberdade em restritiva de direitos, a despeito de terem sido condenados à sanção mínima do tráfico privilegiado (1 ano e 8 meses de reclusão), ou, quando muito, a uma pena menor que 4 anos de reclusão. A menos que cumpram pena por outro motivo, são pessoas que se encontram indevidamente recolhidas ao precário sistema penitenciário, onerando ainda mais a sociedade, que

poderia se beneficiar com serviços comunitários, houvessem as respectivas sanções reclusivas sido convoladas em restritivas de direito. 13. Se a lei é, na visão de julgadores, benevolente com algum tipo de crime, compete ao Congresso Nacional, legitimado pelo voto popular, modificá-la (sempre sujeito, evidentemente, ao controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal). Não cabe ao Poder Judiciário, o uso de discursos metajurídicos de matiz ideológico ou moral, para incrementar o rigor do sistema punitivo e para contornar, com argumentos aparentemente jurídicos, os limites impostos pela lei penal e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, os quais, como visto, pela Constituição da República têm a especial competência para interpretar e uniformizar a lei federal e a Constituição em última instância, ante idênticas situações fáticas. 14. Estudo feito pelo Instituto Conectas (relatório disponível no sítio do instituto na web) conclui que “ainda que a decisão do STF no HC 118.533 tenha sido o reconhecimento do tráfico privilegiado como um crime comum, afastando-se a hediondez dos casos em que há aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33, com a presente pesquisa verifica-se que juízes de primeira instância, em São Paulo, continuam aplicando tratamento desproporcional ao delito, em comparação com outros delitos sem violência de igual pena.” Alguns julgados – prossegue o relatório – “são expressos em sua afronta à jurisprudência dominante das cortes superiores, tecendo palavras fortes contra a

evolução interpretativa e constituindo, dentro da sua esfera de poder, um espaço blindado contra o tratamento proporcional aos condenados por tráfico de drogas, em qualquer grau.” 15. Pelos dados do Núcleo de Segunda Instância e Tribunais Superiores - Brasília/DF, a Defensoria Pública de São Paulo em 2019, dos 11.181 habeas corpus impetrados no STJ, a ordem foi concedida em 6.869 feitos, 61,43% das impetrações. Mais ainda, aquela Defensoria evidenciou que, no período da pandemia, conforme Levantamento do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo, em casos de reconhecido tráfico de menor monta (pouca quantidade de drogas, réus com bons antecedentes e sem provas de anterior atividade ilícita e de integração a organização criminosa), de 64 casos em que Câmaras Criminais do TJSP mantiveram a condenação de acusados por tráfico privilegiado, 53 foram reformadas pelo STJ, ou seja, cerca de 82,80% dos pacientes obtiveram decisão concessiva. 16. Esses dados são a tradução, inequívoca e indesmentível de que o volume de trabalho das Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça, ocupadas em mais de 50% por habeas corpus oriundos do Tribunal de Justiça de São Paulo (dos 68.778 habeas Corpus distribuídos no STJ em 2019, 35.534 vieram daquele Tribunal), em boa parte se resume a simplesmente reverter decisões que, contrárias às súmulas e à jurisprudência das Cortes Superiores, continuam a grassar, crescentemente, em algumas das 16 Câmaras Criminas daquele Tribunal. 17. Essa insistente desconsideração de alguns órgãos judicantes às diretrizes normativas derivadas das Cortes de Vértice produz um desgaste permanente da função jurisdicional, com anulação e/ou repetição de atos, e implica inevitável lesão financeira ao erário, bem como gera insegurança jurídica e clara ausência de isonomia na aplicação da lei aos jurisdicionados. 18. Em suma, diante da mesma situação factual – tráfico de pequena monta, agente primário, sem antecedentes penais, sem prova de vínculo com organização criminosa e de exercício de atividade criminosa (que não seja, é claro, a específica mercancia ilícita eventual que lhe rendeu a condenação) –, há de reconhecer-se que: 18.1. A Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), em seu art. 112, § 5º (com a redação que lhe conferiu a Lei n. 13.964/2019) é expressa em dizer que “§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”; 18.2. O Ministério Público, a par da função exclusiva de exercitar a ação penal pública, é também constitucionalmente incumbido da “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da C.R.), e deve agir de acordo com critérios de objetividade, compromissado, pois, com o direito (custos iuris) e com a verdade (obbligatio di veritá, na dicção de LUIGI P. COMOGLIO e VLADIMIRO ZAGREBELSKY, Modelo accusatorio e deontologia dei comportamenti processuali nella prospettiva comparatistica. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milano: Giuffrè,

ano 36, fasc. 2 - aprile-giugno/1993, p. 484). Logo, a acusação formulada pelo Ministério Público há de consubstanciar uma imputação responsabilmente derivada da realidade fático-jurídica evidenciada pelo simples exame do inquérito policial, muitas vezes já indicativa de que não se cuida de hipótese de subsunção da conduta do agente ao crime de tráfico de drogas positivado no caput do art. 33 da LAD.

18.3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores - quer por meio de súmulas (verbetes n. 718 e 719 do STF e 440 do STJ), quer por meio de julgamentos proferidos pela composição Plena do Supremo Tribunal Federal, seguidos por inúmeros outros julgamentos da mesma Corte e do STJ - é uníssona e consolidada no sentido de que:

18.3.1. Não se pode impor regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito e sem a idônea motivação, que não pode decorrer da mera opinião do julgador; 18.3.2. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33. § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em semiaberto, desde que por motivação idônea, não decorrente da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador; 18.3.3. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nas condições e nas ressalvas da alínea anterior, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 18.3.4. O autor do crime previsto no art. 33, § 4º da LAD não pode permanecer preso preventivamente, após a sentença (ou mesmo antes, se a segregação cautelar não estiver apoiada em quadro diverso), porque: a) O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal - e copiosa jurisprudência das Cortes Superiores - afastou a vedação à liberdade provisória referida no art. 44 da LAD; b) Não é cabível prisão preventiva por crime punido com pena privativa máxima igual ou inferior a 4 anos (art. 313, I do Código de Processo Penal; c) O tempo que o condenado eventualmente tenha permanecido preso deverá ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade (art. 387, § 2º do CPP), o que, a depender do tempo da custódia e do quantum da pena arbitrada, implicará imediata soltura do sentenciado, mesmo se fixado o regime inicial intermediário, ou seja, o semiaberto (dado que, como visto, não se mostra possível a inflação de regime fechado ao autor de tráfico privilegiado).

19. Essas são, portanto, as diretrizes que devem ser observadas - e normalmente o são, pela maioria de juízes e tribunais de todo o país -, por decorrerem de precedentes qualificados das Cortes Superiores (súmulas de jurisprudência, julgamentos pelo Tribunal Pleno do STF, recursos especiais julgados sob o rito dos recursos repetitivos do STJ, e extraordinários em repercussão geral, pelo STF), sobre questões jurídicas assentadas a partir da mesma situação fática, sempre ressalvada, naturalmente, a eventual indicação de peculiaridades do caso examinado, a permitir, mediante idônea e responsável motivação, distinguir a hipótese em julgamento da que fora decidida nos referidos precedentes.

20. Na espécie, a gravidade excepcional do delito não se sustenta, visto que o crime foi praticado em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delitiva em apreço e, embora apreendidas cocaína e crack, a quantidade da droga, ao contrário do afirmado, não foi relevante (5,6 g no total).

21. Habeas Corpus concedido, para:

21.1. Em relação ao paciente individualizado na impetração, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena.

21.2. Em relação aos presos que, conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, se encontrem na mesma situação (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses, em regime fechado), fixar o regime aberto.

21.3. Em relação aos presos condenados, pelo delito de tráfico privilegiado, a penas menores do que 4 anos de reclusão - salvo os casos do item anterior - determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de progressão ao regime aberto em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente.

21.4. Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se imponha - devendo

haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena. Determinação para que se dê cumprimento desta ordem de Habeas Corpus, inclusive para que se providencie, junto aos respectivos juízos, a imediata expedição de alvarás de soltura aos presos que, beneficiados pelas medidas ora determinadas, não estejam presos por outros motivos. (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 04/09/2020).

E mais:

"HABEAS CORPUS" - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, § 4º)- CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - UTILIZAÇÃO DESSE FATOR DE REDUÇÃO, EM GRAU MENOS FAVORÁVEL, SEM ADEQUADA JUSTIFICAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL - QUANTIDADE (OU NATUREZA) DAS DROGAS APREENDIDAS COM O CONDENADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL A SER PONDERADA, SOMENTE, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL (LEI Nº 11.343/2006, ART. 42)- CRITÉRIO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO, DE NOVO, SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO QUE VEDA O "BIS IN IDEM", NA TERCEIRA FASE DA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA, PARA JUSTIFICAR A APLICAÇÃO, EM GRAU MENOS FAVORÁVEL AO CONDENADO, DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, § 4º)- PRECEDENTES - CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS NOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, "CAPUT" E § 1º, E NOS ARTS. 34 A 37, TODOS DA LEI DE DROGAS - RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA LEGAL QUE VEDA, "IN ABSTRACTO" (ART. 33, § 4º, E ART. 44), ESSA CONVERSÃO (HC 97.256/RS) - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NOS CASOS DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES, EM REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO QUE O REGIME FECHADO (HC 111.840/ES) - CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE HIPÓTESE DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - PEDIDO DEFERIDO EM PARTE. . - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 97.256/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO, reconheceu a inconstitucionalidade de normas constantes da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), no ponto em que tais preceitos legais vedavam a conversão, pelo magistrado sentenciante, da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos. - O Poder Público, especialmente em sede penal, não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal, ainda mais em tema de liberdade individual, acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade, que traduz limitação material à ação normativa do Poder Legislativo. . - Atendidos os requisitos de índole subjetiva e os de caráter objetivo previstos no art. 44 do Código Penal, torna-se viável a substituição, por pena restritiva de direitos, da pena privativa de liberdade imposta aos condenados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, "caput" e § 1º, e 34 a 37, todos da Lei nº 11.343/2006. - Possibilidade de o condenado pelo crime de tráfico privilegiado de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o regime fechado. Precedente do Plenário (HC 111.840/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, "Informativo/STF nº 672").

O crime de tráfico foi equiparado, legalmente, aos hediondos, motivo pelo qual, em relação a ele, o condenado Paulo não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, mesmo porque a reincidência impede a substituição. Também compartilhado do entendimento de que o crime de tráfico de drogas é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias envolvidas, de modo que a concessão de regime menos gravoso ou mesmo de qualquer outro benefício, como a substituição da pena ou mesmo do sursis, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou mesmo reprovação da prática delitiva, gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, do Código Penal, além de verdadeira sensação de impunidade. Por conta dos mesmos fundamentos, Paulo deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois é o que melhor se amolda para início do cumprimento da pena por crime tão grave e atroz contra a saúde pública. Qualquer outro regime prisional não se coaduna com o tráfico, diante de tantas mazelas que sabidamente a droga provoca.

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da

impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese. Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014).

Ele também não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de:

a) ABSOLVER MATHEUS FELIPE ALVES GOMES DE MORAES e PAULO HENRIQUE CARDOSO PEREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, da imputação do artigo 35, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, que lhes foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal;

b) CONDENAR PAULO HENRIQUE CARDOSO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 700 (setecentos) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica;

c) CONDENAR MATHEUS FELIPE ALVES GOMES DE MORAES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, § 4º, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, e mais 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica.

Recomende-se na prisão onde Paulo estiver.

Quanto a Matheus, vislumbrando a presença dos pressupostos de aplicação das penas restritivas de direito, nos termos dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Primeiramente, pela prestação de serviços gratuitos à comunidade, devendo o condenado prestar uma hora de tarefa por dia de condenação, devendo tal serviço, ainda, ser prestado aos sábados, domingos e feriados, ou dias úteis, desde que não haja prejuízo a sua jornada normal de trabalho.

Caberá ao Juiz da Execução designar a entidade ou programa comunitário ou estatal,

junto ao qual o condenado irá trabalhar gratuitamente.

Ao depois, nos termos do § 1º, do artigo 45, do Código Penal, pela pena de 1 (um) salário-mínimo, a ser destinado a entidade pública ou privada